

1515710-49.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... transitadas em julgado pelo cometimento de tráfico de drogas (fls. 65/67), ostentando reincidência e maus antecedentes, além de que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando do cometimento dos fatos aqui narrados, e portanto, não deve ser beneficiado, ainda mais por uma tese que não tem amparo legal.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515710-49.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515710-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

IANCLEITON TEIXEIRA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

Autos recebidos apenas em 07/01/22, quando de retorno de afastamentos devidamente autorizados, conforme publicação em Diário Oficial.

IANCLEITON TEIXEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, combinado com art.61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, pois, segundo apurado, no dia 27 de junho de 2021, entre 07h e 09h, em período de calamidade pública, nos termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20-03-2020, na Rua Ingá Natal, nº 159, Grajaú, nesta cidade e comarca, agindo de maneira livre, consciente e previamente ajustado e com unidade de propósitos e desígnios com um indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, por duas vezes em continuidade delitiva, subtraiu em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistente em 06 kg de fios de cobre, avaliados em R\$ 210,00, pertencentes às vítimas J.C.M. e M.L. dos S.

A denúncia foi recebida (fls. 112/114), o réu foi citado e notificado. Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a duas vítimas e as testemunhas Milena e Douglas. A acusação insistiu na oitiva de uma testemunha faltante, e foi designada audiência de continuação na qual a testemunha Ivone foi ouvida e o réu foi interrogado. (fls. 157/158).

Encerrada a instrução, em suas alegações, o Ministério Público buscou a parcial procedência da ação, com a condenação do réu como incurso no art. 155, § 4º,

incisos I e IV e no art. 155, "caput", combinados com art. 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

A Defesa do réu, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu pelo reconhecimento do princípio da Insignificância (art. 386, III do Código de Processo Penal) ou pela insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente, em caso de eventual condenação requereu o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, no tocante aos dois delitos pelos quais o réu está sendo processado, a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante da calamidade pública e fixação de regime inicial diverso do fechado.

Por primeiro, antes de analisar as provas e os pedidos das partes, necessário se faz a regularização do andamento processual.

Isso porque, verifica-se que, não foi apresentada a resposta à acusação pelo réu, não obstante tal fato, o acusado foi devidamente citado, notificado, compareceu em ambas as audiências de instrução designadas, foi interrogado após conversa com sua Defesa, e assim teve ampla oportunidade de defesa, nada tendo alegado a este respeito em suas alegações finais.

Assim sendo, dou por suprida a falta desta peça, já que sua não apresentação em juízo, não causou qualquer tipo de prejuízo à Defesa do acusado.

Nesse sentido, aliás, entendimento pretoriano a seguir exposto:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI N. 11.719/2008. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ.2. Consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio *pas de nullité sans grief*. No mesmo sentido, preconiza o enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".3. Na hipótese vertente, quanto à alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de resposta à acusação, nos termos da Lei n. 11.719/2008, a instância ordinária afirmou que "os acusados foram notificados para responderem por escrito a denúncia, que a peça acusatória foi recebida após a apreciação das teses defensivas, que os réus foram citados e designados seus interrogatórios antes da vigência da Lei 11.719/2008, que alterou o procedimento penal ordinário, não há que se falar em nulidade, pois os atos foram regularmente praticados pelo magistrado primeiro em consonância com a regra procedimental vigente à época, considerando-se, sobretudo, que a norma de direito processual não possui efeito retroativo" (e-STJ fls. 5.094). Assim não há falar em nulidade ante a ausência de prejuízo.4. Quanto à inversão da ordem do interrogatório, o agravante deixou de impugnar fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (AgRg no REsp 1617950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 17/11/2020)."

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo a análise do mérito da causa.

Primeiramente, não há que se falar em atipicidade do fato, em razão do princípio da insignificância.

Isso porque se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país.

Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do

agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Verifica-se no caso em tela, que réu possui outras condenações transitadas em julgado pelo cometimento de tráfico de drogas (fls. 65/67), ostentando reincidência e maus antecedentes, além de que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando do cometimento dos fatos aqui narrados, e portanto, não deve ser beneficiado, ainda mais por uma tese que não tem amparo legal.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente, possuidor de maus antecedentes, que reitera no mundo do crime e demonstra habitualidade delitiva, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 603.539/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020) (Grifei)"

Não é diverso o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2º E 4º, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento (HC 94765, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00575).

Dessa forma, afasto o reconhecimento da insignificância no caso dos autos.

No mais, sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade e a autoria dos delitos de furto restaram cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega dos objetos subtraídos, auto de reconhecimento pessoal a fls. 13, fotografias de fls. 32/33, tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é incontestável.

O réu ao ser ouvido na Delegacia de Policial confessou a prática dos dois delitos de furto. Disse que no dia dos fatos "(...) realizou os dois furtos do dia de hoje na companhia de Juninho; que não soube informar a qualificação de Juninho; que não soube informar onde estão as coisas furtadas da primeira residência; que apanhou dos populares quando tentava fugir do local, não sabendo identificar os agressores; que não foi agredido pelos policiais militares e, menos ainda, pelos policiais civis; que não foi agredido pelas vítimas, as quais tentaram fazer cessar as agressões". (fls. 16).

Já ao ser interrogado em juízo, disse que apenas tentou subtrair os fios que pertenciam ao proprietário da segunda residência. Alegou que é usuário de drogas e estava em abstinência de entorpecentes, e ao visualizar uma "brecha" debaixo do portão, tentou pegar os fios que estavam no chão e acabou sendo detido pela vizinhança, sem conseguir subtraí-los. Afirmou ainda que na ocasião estava em cumprimento de regime aberto. Negou ter furtado a casa de Marcos.

A versão dada pelo réu, em juízo, além de ser diversa da por ele apresentada quando foi preso em flagrante, se mostrou completamente dissociada dos elementos colhidos nos autos.

Com efeito, apesar de ter confessado apenas uma tentativa de furto na residência da vítima Jorge, não soube explicar o motivo pelo qual foi reconhecido pela vizinha da outra residência como sendo um dos furtadores ou mesmo soube explicar quem era "Juninho", nome indicado em sede policial como seu comparsa no cometimento dos furtos. Apenas negou de forma vaga que não havia cometido o primeiro furto. Diante da falta de consistência da versão apresentada, vez que não se mostrou corroborada em nenhum outro elemento de prova, esta se torna demasiadamente frágil, ainda mais se cotejada com os demais depoimentos dos autos.

A vítima M. L., ao ser ouvida em juízo, informou que estava trabalhando no período da noite e ao retornar a sua residência, foi avisada pela vizinha da frente que alguém teria invadido sua residência, tentando levar um micro-ondas antigo, mas como a vizinha gritou, eles fugiram levando consigo um saco cheio de fios.

Diante disso, foi até o local que estava em construção e constatou que foram subtraídos fios de telefone e de cobre de sua residência. Disse ainda que a construção estava fechada com uma madeira e que para entrar no local, os indivíduos acabaram danificando tal proteção. Não soube precisar quantos quilos de fios foram levados. Ressaltou, ainda, que sua vizinha da frente se chama Ivone e segundo ela, foram dois os indivíduos que subtraíram os fios. E que posteriormente foi informado que um desses dois rapazes ainda voltou ao local para subtrair alguns fios da residência da vítima Jorge durante o dia e que populares o viram e impediram o furto e segundo Ivone esse rapaz detido pelos populares era um daqueles que havia furtado sua residência na noite anterior.

A vítima J. C.M., por sua vez, relatou que estava na cozinha de sua residência quando ouviu um barulho e um vizinho o chamou. Assim que saiu para ver o que estava acontecendo, deparou-se com alguns vizinhos que teriam presenciado a entrada do réu em sua residência e em razão disso, os cercaram com os fios subtraídos até a chegada da polícia militar, impedindo assim a subtração.

Não conseguiu reconhecer o réu em juízo, mas afirmou que se tratava de um homem moreno e magro. Informou que foram subtraídos aproximadamente 02 quilos de fio, mas que foram restituídos, vez que os vizinhos o alcançaram saindo de sua residência. Era só um indivíduo. Ficou sabendo que essa mesma pessoa também havia furtado a casa da vítima Marcos. Uma vizinha teria presenciado o furto na casa de Marcos, a Sra. Ivone que mora na frente de Marcos.

A testemunha Ivone após descrever o réu como sendo um indivíduo moreno e baixo, reconheceu o acusado, sem qualquer sombra de dúvidas. Ao ser indagada sobre os fatos, afirmou que no dia do ocorrido, estava na lavanderia de sua casa e viu o réu juntamente com outro indivíduo, arrombando o portão de madeira da casa de seu vizinho Marcos e ali entrando. Logo em seguida ambos saíram carregando um saco em suas mãos. Posteriormente, tomou conhecimento de que um indivíduo estava detido por populares por ter ingressado na casa de outro vizinho de nome Jorge e diante disso foi ao local, e ao ver o réu saindo do portão da vítima Jorge de imediato o

reconheceu como sendo um dos indivíduos que haviam entrado na casa de Marcos. O policial militar Douglas por sua vez, em juízo, após prestar o compromisso de dizer a verdade, relatou que no dia dos fatos foi acionado por populares que teriam detido um rapaz que estava praticando furtos nas residências das redondezas e apenas apresentou as partes na Delegacia de Polícia mais próxima. Já a outra policial militar Milena, também ouvida em juízo não se recordou dos fatos apurados nestes autos.

A materialidade delitiva restou comprovada, além da prova testemunhal produzida em Juízo, pelo Boletim de Ocorrência e auto de exibição e apreensão e entrega dos objetos subtraídos.

Por fim, não se pode deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade. Não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

E diante disso, considerando os depoimentos colhidos nos autos e ainda, porque o réu não trouxe aos autos quaisquer provas da versão apresentada em juízo, a condenação é medida que se impõe.

No entanto, a ação deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, no que toca ao furto praticado contra a vítima M.L. dos S., apenas a qualificadora da comparsaria, restou comprovada nos autos.

Com efeito, a testemunha Ivone foi firme em dizer que o réu não agiu sozinho e estava em companhia de um outro indivíduo. Veja-se ademais que o réu em seu depoimento em sede policial confirmou o relato da testemunha, tendo afirmado que agiu na companhia de "Juninho".

Já no que toca as outras duas qualificadoras, quais sejam, "escalada e rompimento de obstáculos", embora a mesma testemunha Ivone, tenha dito que viu o réu arrombando a porta de madeira da casa de seu vizinho, tal fato, não veio comprovado nos autos, como muito bem ponderado pelas partes, já que para a configuração dessa qualificadora, é indispensável o laudo pericial.

Firme é a jurisprudência quanto à questão: "É imprescindível ao reconhecimento, em tema de furto, da qualificadora da escalada, e do rompimento de obstáculos, a realização de exame pericial, não sendo este suprido pelo simples ato de verificação e descrição do local do delito assinado pela autoridade policial" (TJSC, JCAT 91/489).

No mesmo sentido: "sem regular exame pericial, impossível se torna o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, sendo, aliás, pacífica a jurisprudência neste sentido" (TACRIM SP Ap. 477.743 Rel Juiz Lustosa Goulart - 2ª C. - J 12.11.87 - Un).

Quanto a escalada, por sua vez, além da falta do laudo pericial, necessário a sua comprovação, veja-se que nenhuma das testemunhas confirmou que o réu teria escalado as madeiras, para conseguir entrar na residência.

No que toca ao furto cometido contra a vítima J.C.M., nenhuma das qualificadoras restaram comprovadas, no bojo desses autos, a própria vítima J.C.M., e a testemunha presencial do furto anterior apenas reconheceram o réu como sendo a pessoa que foi detida pelos vizinhos no momento em que se apoderava dos fios e ainda afirmaram que nenhuma outra pessoa foi com ele detida, ou vista, naquela oportunidade e nada disseram sobre arrombamento ou mesmo destruição de obstáculos.

Por fim, respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada esse delito de furto foi tentado, já que o réu foi impedido de consumir a subtração dos fios de cobre após ser detido e até mesmo "enrolado" nos fios pelos vizinhos da vítima, que assim o mantiveram até a chegada da polícia, não sendo para esta magistrada possível se falar em consumação do delito.

Caracterizadas, portanto, as infrações penais a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

1) Do crime de furto qualificado:

O réu é reincidente, consoante certidão de fls. 65/67. Como possui duas condenações diversas, uma delas condenações será considerada na segunda fase de aplicação de

pena, como reincidência (Autos nº 0060944-22.2017.8.26.0050 da 17ª Vara Criminal de São Paulo), e a outra (Autos nº 0065366-06.2018.8.26.0050 da 22ª Vara Criminal de São Paulo), será tida como maus antecedentes nesta primeira fase. Além disso verifica-se que o delito foi cometido mediante uma qualificadora, portanto a pena base deve ser aumentada em 1/5, chegando-se a 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, é o caso de se reconhecer a agravante da reincidência (Autos nº 0060944-22.2017.8.26.0050 da 17ª Vara Criminal de São Paulo) e que o delito foi cometido sob a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP – PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

“(…) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

E ainda: “O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante

da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

Não há que se reconhecer a confissão do réu, já que este delito em juízo foi por ele negado veementemente, o que para esta magistrada afasta a possibilidade de reconhecimento, em sede de sentença judicial.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a se considerar. que se considerar causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela razão torno a pena de 2 anos, 10 meses e 16 dias e 14 dias-multa definitiva.

2) Do crime de furto tentado:

O réu é reincidente, consoante certidão de fls. 65/67. Como possui duas condenações diversas, uma delas será considerada na segunda fase de aplicação de pena, como reincidência (Autos nº 0060944-22.2017.8.26.0050 da 17ª Vara Criminal de São Paulo), e a outra (Autos nº 0065366-06.2018.8.26.0050 da 22ª Vara Criminal de São Paulo), será tida como Maus antecedentes nesta primeira fase. Assim sendo a pena base deve ser aumentada em 1/6, chegando-se a 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, é o caso de se reconhecer a agravante da reincidência (Autos nº 0060944-22.2017.8.26.0050 da 17ª Vara Criminal de São Paulo) e que o delito foi cometido sob a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, pelo motivos e fundamentos acima expostos, respeitadas é claro, as posições em contrário.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. O crime, contudo, foi tentado, já que o réu para esta magistrada foi impedido de consumir o furto, sendo "enrolado" nos fios que pretendia subtrair até a chegada da polícia. Mais uma vez, a se aceitar indistintamente a posição que vem se firmando na jurisprudência o crime de furto tentado não mais existirá o que, ao certo, não é o escopo legal.

Assim sendo, considerando o iter criminis praticado pelo réu que foi surpreendido pelos vizinho quando saía da casa da vítima, com os fios de cobre em mãos, a pena deve ser diminuída pela metade, totalizando 7 meses de reclusão e 05 dias-multa.

Muito embora os delitos tenham sido cometidos nas mesmas circunstâncias de local e tempo, não foram praticados nas mesmas condições, já que o primeiro furto foi praticado mediante o concurso de pessoas e já o segundo na modalidade simples. Assim sendo, para esta magistrada, não há como se aplicar o crime continuado na espécie e as penas devem, portanto, ser somadas, já que estamos diante de cumulo material de delitos.

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para o fim de condenar o réu como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, e no art. 155, caput, combinado com art. 14, inciso II, na forma do art. 69, "caput", todos do Código Penal, aplicando-se ao réu a pena de 3 anos, 05 meses e 16 dias de reclusão e 16 dias-multa, fixados no mínimo legal, já que não há nos autos provas das condições financeiras do acusado, que foi inclusive defendido pela Defensoria Pública local. Incabível ao caso concreto a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão da reincidência em crime doloso e ainda porque, tal substituição não lhe convém.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis aplicadas ao réu, além de sua dupla reincidência. Veja-se que o acusado estava em cumprimento de pena em regime aberto consoante certidão de fls. 65/67, e novamente voltou a delinquir, demonstrando que somente o cárcere lhe convém.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Por fim é sabido que a imposição do regime prisional independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma.

E, no caso, o regime mais adequado ao cumprimento da pena reclusiva imposta é fechado, haja vista que o acusado é duplamente reincidente e estava em cumprindo pena em regime aberto no momento em que foi preso em flagrante.

Nessa conformidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela sentença de 1º grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início da execução da pena" (RT 725/533).

"O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2º, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido" (STJ, Resp. 84669/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 14.4.97).

"Embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado" (STJ, AgRg no Resp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Por fim, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou.

Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública.

De outra banda, em razão do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal já com a nova redação, reviso a decisão que decretou sua prisão preventiva e o faço para manter a segregação cautelar pelos fundamentos acima impostos.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD e



comunique-se a vítima consoante disposição legal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA